

1500287-69.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171372/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25746787 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2171372 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DANIEL SCARABELLO

Em 28 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/ESuL47_qasJGroRoHI88t0sBufwnn8XvHyvQoN40YH2TlQ?e=7IaBCv

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500287-69.2022.8.26.0598 - Controle 2022/000903

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171372/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25746787 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2171372 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAICON DANIEL SCARABELLO

Em 28 de setembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Alexandre de Campos Bovolin, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Vinicius Raymundo Stoppa OAB 314740/SP, Advogado, ora defendendo o acusado MAICON DANIEL SCARABELLO; o acusado referido; e as testemunhas Paulo César Balduin e Bruno Beojone Messi, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. MAICON DANIEL SCARABELLO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (p. 5097). A

denúncia foi recebida em 19 de agosto de 2022. (p. 5101) e o réu foi citado (p. 5131). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. O Defensor requereu a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo de exame químico-toxicológico. Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a guarda dos entorpecentes para terceiro, conduta que alegou praticar por menos de um mês antes dos fatos. O policial civil Paulo Balduin confirmou o encontro das drogas na residência do acusado, após obtenção de informações de que ele estaria guardando drogas para um traficante. A apreensão também foi confirmada pelo seu colega Bruno. Pois bem. Incontroversa a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes na residência do réu, incompatíveis com a destinação para consumo. O réu admitiu o tráfico em seu interrogatório judicial e nada há nos autos a afastar a credibilidade do seu relato, que, de resto, foi confirmado pelos policiais ouvidos em juízo. Nesse sentido: "Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (JTACrimSP 93/239). A alegação de dificuldade financeira, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, já que o acusado é apto para o trabalho e deveria ter buscado meios lícitos para incrementar o seu sustento. Não há dúvida, nesse contexto, da prática pelo acusado do crime de tráfico, já que o artigo 33 da Lei 11.343/06 elenca, além da venda, diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. Assim, de rigor a procedência da ação para o fim de condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Passo, pois, a dosar a pena. Na primeira fase, atentando ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade e natureza de entorpecentes apreendida. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e torno a pena ao mínimo legal. Na terceira fase, em que pese o teor da r. manifestação ministerial, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado dedicava-se, há tempo considerável, a tal atividade criminosa ou integrasse organização criminosa. Todavia, cumpre observar que referido preceito legal fixa os requisitos necessários à sua aplicação, mas não estabelece parâmetros para escolha do quantum de diminuição a ser extraído entre as frações de 1/6 e 2/3. A esse respeito, oportuna a citação do Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux, esposada em seu voto no Habeas Corpus nº 111.097-MG: "Destarte, se se entender pela ocorrência de bis in idem em decorrência da consideração das circunstâncias atinentes à quantidade e à qualidade da droga na majoração da pena-base e na dosagem da minorante do § 4º da Lei de Drogas, o magistrado ficará sempre adstrito à aplicação da minorante na fração máxima, tornando letra morta o preceito legal que determina seja ela aplicada na forma escalonada, por isso, a conclusão há de ser pela ausência de sobreposição, notadamente porque a pena-base e a minorante têm finalidades distintas: a primeira encontra justificativa na sanção necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, e a segunda visa a contemplar, com o abrandamento da punição, não necessariamente com a fração máxima de 2/3, o agente primário e de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INSTRUMENTO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. MENOR FRAÇÃO. 1. O legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deixando de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e maior frações indicadas para a mitigação, disciplinando a doutrina e a jurisprudência que devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do e Supremo Tribunal Federal especialmente o disposto no art. 42 da Lei Antitóxicos. 2. Juízo de proporcionalidade que admite a aplicação do redutor no percentual mínimo de 1/6, de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do CP, dada a

quantidade e a espécie de entorpecente encontrado em poder do acusado. 3. Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO." (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.403.921-MG – 2011/0085663-6 – 6ª T - rel. Ministro Vasco Della Giustina, 23.08.2011, v.u.). Pois bem. Destarte, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendida, diminuo a pena do crime de $\frac{1}{2}$, tornando-a definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. Considerando a primariedade do réu e ausência de antecedentes, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelos motivos esposados na primeira fase e também pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, de modo que a concessão dos benefícios mencionados, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, CP. A pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal, à mingua de elementos que denotem condição financeira que permita a majoração. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão

de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa

condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu MAICON DANIEL SCARABELLO, qualificado nos autos, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. O réu não poderá apelar em liberdade, pois permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva. Não é demais observar que o réu responde a processo por roubo que se encontrava suspenso desde 2019 nos termos do art. 366, CPP, o que reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que deseja recorrer. O Réu e o Defensor informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: MAICON DANIEL SCARABELLO

RG: 48103655, RJ: 224414201-33

Data De Nascimento: 19/02/1992

Filiação: pai CARLOS FERNANDO SCARABELLO, mãe MARIA APARECIDA MARIANO SCARABELLO

Residência: RUA LIBÓRIO SANTÂNGELO, 70, JARDIM SANTO ONOFRE, RUA LIBÓRIO SANTÂNGELO
- CEP 17209-309, JAU-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.